

PARECER/2025/7

PEDIDO

O Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPd) a emissão de parecer sobre o “Projeto de Decreto-Lei que aprova o programa de oferta de assinaturas digitais de publicações periódicas a todos os jovens entre os 15 e os 18 anos – MAP – (Reg. DL 381/XXIV/2024)”; e o “Projeto de Portaria que aprova os procedimentos relativos à adesão das entidades proprietárias de publicações periódicas ao programa acima referido”.

O pedido formulado e o presente parecer enquadram-se nas atribuições e competências da CNPD, enquanto entidade administrativa independente com poderes de autoridade para o controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, conjugada com a alínea b) do n.º 3 do artigo 58.º e com o n.º 4 do artigo 36.º, todos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que executa na ordem jurídica interna o RGPD.

ANÁLISE

O presente pedido de pronúncia tem por objeto o projeto de Decreto-Lei (doravante, Projeto) que aprova o programa de oferta de assinaturas digitais de publicações periódicas a todos os jovens entre os 15 e os 18 anos – MAP – (Reg. DL 381/XXIV/2024)”; e o “Projeto de portaria que aprova os procedimentos relativos à adesão das entidades proprietárias de publicações periódicas ao programa acima referido.

O referido Programa consiste “[...] na oferta de uma assinatura digital, com validade de dois anos, de uma publicação periódica, a todos os jovens entre os 15 e os 18 anos, inclusive”, a realizar através de subscrição sob a forma digital.

Destarte, quanto ao alcance do seu âmbito material, o Projeto vem desenhar qual a natureza e âmbito de aplicação do programa, quais as publicações periódicas excluídas, o regime de assinaturas e seu pagamento, e as condições de adesão, divulgação, e avaliação do referido Programa.

A matéria respeitante à proteção de dados pessoais vem remetida para um único artigo (9.º), que sob epígrafe “Proteção de dados” assim declara: *“As entidades intervenientes na execução do Programa garantem que o*

tratamento de dados pessoais respeita o quadro legal aplicável, designadamente a Constituição da República Portuguesa, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto."

Como tem sido posição reiterada desta Comissão, a mera inclusão de cláusula genérica de tipo declarativo sobre o cumprimento das regras em vigor não se afigura capaz de preencher ou satisfazer os ditames – imperativos – que a matéria de proteção de dados reclama.

Cumprir recordar que a proteção de dados pessoais se encontra diretamente prevista na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia¹, e os seus tratamentos deverão obedecer aos princípios e matrizes amplamente reconhecidos na legislação europeia e nacional -inclusivamente constitucional²- que se difunde dessa identidade.

Assumindo a dimensão jurídica de direitos fundamentais, os dados pessoais e sua proteção formam parte cimeira desse património nuclear de direitos e liberdades na qual assenta a vivência de uma sociedade democrática, com as consequências que tal dignidade reclama, enquanto uma das suas manifestações.

Como matéria jusfundamental, a proteção de dados pessoais goza, também, da consagração de um conjunto de princípios próprios, que emergem na dependência axiológica daquele núcleo essencial, no sentido de lhes confirmar eficiência, e impõe-se de forma juridicamente vinculativa, e diretamente, a todos os Estados-Membros, como é o caso, desde logo, do RGPD e suas normas.

Tal servirá para dizer que, quando o Legislador declara que os núcleos conformadores e as condições executantes das normas que pretende construir cumprirão a matéria prevista na Constituição da República Portuguesa ou, especificamente quanto a esta matéria, no RGPD e sua Lei de Execução, nada está a acrescentar para além do natural pressuposto do seu exercício legislativo, já que, sob pena de ilicitude, outra solução não poderia conceber-se.

Daqui decorrerá que, quando o Legislador se encontre perante regulação que implique o tratamento de dados pessoais, a obrigação que sobre si impende será a de, perante o caso ou tratamento(s) concreto(s) que vêm implicados, estabelecer o regime particular das suas condições que, por um lado, demandam a concretização das regras previstas nos diplomas imperativos que os regulam, e que, por outro lado, consistam na consubstanciação ou subsunção do regime de proteção previsto na Constituição da República Portuguesa e na Legislação Europeia e nacional que enformam essa matéria.

¹ Veja-se o seu artigo 8.º.

² Veja-se o artigo 35.º da CRP, inserido sob o título "Direitos, Liberdades e Garantias".

Apenas se desenhando os sujeitos, fundamentos, fins e o *modus* como os tratamentos serão executados e operacionalizados, em específico, é que se permitirá concluir que são cumpridas aquelas determinações e princípios, o que terá de decorrer de um juízo valorativo de cada tratamento proposto, ponderação essa que, natural e logicamente, decorrem da prévia ontologia e desenho do tratamento que, depois, merecerá -ou não- essa adequada qualificação.

Se nenhum dos termos do tratamento estiver definido, nada se poderá concluir, nem nenhum juízo de proporcionalidade poderá ser concretizado.

Dever-se-á, portanto, de cada vez que um específico tratamento de dados pessoais seja previsto por emanar de conteúdos normativos, regular-se, nesse mesmo documento, e com pelo menos a mesma dignidade, os imperativos concretos capazes de enformar os respetivos tratamentos em causa e que concretizam esses mesmos princípios e seu regime, o que, adiante-se, se encontra omissa neste Projeto.

De resto, a matéria respeitante a Direitos, Liberdades e Garantias, está sujeita ao regime de reserva relativa de competência legislativa prevista no número 1, alínea b) do artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa, o que, adiante-se, superiormente contradiz a possibilidade de regulação de matéria relacionada com dados pessoais através de Portaria, cuja natureza se assume como administrativa e não legislativa, devendo exigir-se, pelo menos, que o instrumento legislativo trace suficientemente o quadro de tratamento, mormente no que toca aos seus fundamentos, fins e garantias dos direitos dos titulares dos dados.

O regime concreto de tratamento de dados, tudo convocando, não é aspeto subsidiário ou secundário ou meramente pratico, antes sendo onde esses direitos fundamentais se realizam e se endereçam aos cidadãos.

Na sua ausência, não é, pois, possível a esta Comissão pronunciar-se sobre o seu valor ou desvalor, o que sacrifica as atribuições, intenções e fins do Legislador quando prevê o parecer prévio deste tipo de matérias a esta autoridade, o que não é desejável.

Isto posto,

O endereçamento para a Portaria *sub iudice*, no que toca ao acesso dos beneficiários ao programa, vem por remissão do artigo 6.º n.º 2 do Projeto: *"2- Os procedimentos relativos à adesão das entidades proprietárias ao regime de assinaturas e ao acesso dos beneficiários ao Programa são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da comunicação social e da juventude e modernização."*

Os beneficiários do Programa serão os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, pelo que tratando-se de pessoas singulares, os seus dados encontram a qualificação de dados pessoais e, bem assim,

repousam no escopo do âmbito do RGPD e demais legislação de proteção de dados pessoais – o que não será o caso as entidades proprietárias de publicações periódicas que pretendam aderir à iniciativa.

Assim, os incisos desse instrumento que se afiguram mais relevantes para esta análise serão o artigo 3.º, 4.º e 6.º, que assim dispõe:

Artigo 3.º

Acesso dos jovens beneficiários ao Programa

- 1 - Os beneficiários acedem ao Programa através do portal Gov.pt, efetuando uma autenticação com recurso à Chave Móvel Digital ou ao Cartão de Cidadão.
- 2 - Durante o processo de autenticação, os beneficiários consentem, automática e expressamente, na recolha dos dados pessoais estritamente necessários à implementação do Programa.
- 3 - Após a autenticação ser bem-sucedida, os beneficiários:
 - a) Indicam o endereço de correio eletrónico destinado a receber informações sobre a subscrição efetuada;
 - b) Escolhem, de entre as publicações periódicas disponíveis, disponibilizadas por ordem alfabética, a que pretendem subscrever.
- 4- A entidade proprietária da publicação periódica selecionada recebe da AMA, I.P., a informação do pedido de subscrição da assinatura ao abrigo do Programa, e disponibiliza prazo máximo de 72 horas, através do endereço de correio eletrónico indicado pelo beneficiário, a forma de acesso à mesma.

Artigo 4.º

Proteção de dados

Após receber a informação sobre o beneficiário, a entidade proprietária torna-se a responsável exclusiva pelo tratamento de dados pessoais, em conformidade com o quadro legal aplicável.

Artigo 6.º

Monitorização e reporte

- 1 - A entidade competente recebe mensalmente da AMA, I.P., relatórios agregados sobre:
 - a) O número de subscrições por publicação periódica;
 - b) A distribuição de subscrições por idade, distrito e concelho de residência dos beneficiários.
- 2- Os relatórios referidos no número anterior contêm informação anonimizada que não permitem a identificação direta dos beneficiários.

- 3- *- A entidade competente não tem, em momento algum, acesso ao nome dos beneficiários nem ao cruzamento de dados que permitam a associação entre o beneficiário e a publicação periódica por si selecionada*

Resulta das referidas normas que os beneficiários que pretendam usufruir do Programa efetuem uma autenticação com recurso à Chave Móvel Digital ou ao Cartão de Cidadão.

No número 2 do artigo 3.º refere-se, porém que: *"2- Durante o processo de autenticação, os beneficiários consentem, automática e expressamente, na recolha dos dados pessoais estritamente necessários à implementação do Programa."*

Diga-se, desde logo, que se desconhece quais sejam "os dados pessoais estritamente necessários à implementação do Programa".

Se é verdade que assim deva ser, de acordo com o princípio da minimização constante no artigo 5.º n.º 1, alínea c) do RGPD [os dados pessoais são: c) *Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados («minimização dos dados»)], o cumprimento do desta determinação haverá de pressupor, antes de mais, a especificação dos dados pessoais e suas categorias que serão tratados, em vista ao juízo de proporcionalidade que a Lei impõe.*

Mutatis mutandis, padece o segmento normativo da vaguidade e confusão metodológica da expressão dos mesmos reparos expendidos supra, i.e., declara-se a conclusão sem se enunciarem as condições que a autorizam. Nesse sentido, os dados concretos que se pretendem tratar em funções dos fins específicos do Programa terão, necessariamente, de estarem indicados, e deles se poderá concluir ou não que constituem os estritamente necessários a esse fim.

Se, por exemplo, se admite que o nome e data de nascimento do beneficiário – ou o endereço de correio eletrónico onde se pretenda receber ou aceder à publicação digital – serão dados necessários e proporcionais, na medida, desde logo, em que servem para determinar as condições subjetivas de adesão ao Programa, como a idade, e a limitação a uma publicação por beneficiário, o mesmo já não se poderia dizer, por exemplo, do nome dos progenitores, ou o número de utente de saúde, ou outros análogos, que não se encontram diretamente relacionados com a fruição do benefício em causa.

Em cadeia, indefinido é o alcance do que se prevê no número 4 do mesmo artigo, i.e., que *"4- A entidade proprietária da publicação periódica selecionada recebe da AMA, I.P., a informação do pedido de subscrição da assinatura ao abrigo do Programa, e disponibiliza prazo máximo de 72 horas, através do endereço de correio eletrónico indicado pelo beneficiário, a forma de acesso à mesma."*, uma vez que se desconhece que informação será essa, bem como a forma de transmissão e como decorrerá o fluxo de informação de dados pessoais, neste caso, para as entidades proprietárias das referidas publicações.

Seguindo a mesma linha expositiva, uma coisa será enviar-se para essas entidades apenas a informação de que o endereço electrónico X é subscritor do Programa e escolheu aquela publicação, outra será passar um conjunto de informação daquele que não seja considerada estritamente necessária ao conhecimento por parte da entidade proprietária, de disponibilização do acesso a este à publicação. Nada, porém, se encontra previsto neste instrumento, o que deverá ser acautelado, ainda para mais quando essa comunicação não estará do domínio do titular do direito/dos dados, e poderá, até, realizar-se sem o seu conhecimento.

Digna de particular atenção se afigura a primeira parte do número 2 do já transcrito artigo 3.º: *"2- Durante o processo de autenticação, os beneficiários consentem, automática e expressamente, na recolha dos dados pessoais..."*

Não resulta claro o que se pretende dizer com "automática", isto é, se com isso se pretende designar um qualquer processo informatizado ou a utilização de um automatismo em sentido amplo ou se, pelo contrário, se pretende constituir uma qualquer operação que possa ser alheia à determinação ou vontade do titular dos dados.

É que, tratando-se no dizer do Legislador, de um consentimento, este deverá cumprir os seus pressupostos que não se compadecem com a segunda interpretação que se provocou.

As condições aplicáveis ao consentimento estão, em geral, previstas nos artigos 4.º n.º11, 6.º n.º1, alínea a) e 7.º desse mesmo Diploma, enquanto elementos materiais de licitude para o tratamento de dados pessoais. Nessa medida, para que o consentimento seja um fundamento lícito para o tratamento de dados, deverá radicar numa manifestação genuína da liberdade volitiva do titular do direito - condição prévia, e não meramente acessória, para a licitude desse tratamento-, bem como no facto do titular dos dados dispor de um efetivo/real controlo sobre os mesmos.

O papel crucial do consentimento -e seu regime, que lhe dá identidade- para o tratamento de dados é realçado, desde logo, nos artigos 7.º e 8.º da CDFUE, onde se declara, respetivamente, que, *"Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações."* e que *"Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respetiva retificação."*

Assim, como afirma o Legislador Europeu, o consentimento tem de ser livre, específico, informado e inequívoco, conceitos que, constituindo coordenadas valorativas, exigem a sua reflexão no tratamento concreto e no respeito do recorte das suas particulares dimensões.

A liberdade de consentimento pressupõe uma verdadeira escolha, uma determinação autónoma e de domínio dos titulares dos dados em relação aos seus direitos. Como corolário deste princípio, não pode o titular dos dados ser coagido, por forma nenhuma, a dar o seu consentimento, ou sofrer quaisquer consequências negativas no caso de não consentir num certo tratamento.

Dito doutro modo, o consentimento nunca poderá ser livre se não for suscetível de ser recusado ou retirado sem prejuízo para o seu exercitante, ou for obtido sob alguma forma de pressão ou influência direta ou indireta capaz de afetar o núcleo de conformação do titular do direito, bem como, igualmente, se puder ser confundido com matéria que não seja disponível ou advir de tratamentos que encontrarão o seu fundamento jurídico noutra causa e, com isso, se desvirtuar o conteúdo da declaração. Perturbado ou deturpado o pleno nexu volitivo, sacrificar-se-á a liberdade de livremente consentir.

Por maioria de razão, nesta aceção, livre não será, também, o consentimento, se, no conjunto contextual de elementos informativos a prestar ao declarante, essa confusão servir uma errada representação do titular que possa ter consentido em função de propósitos que não se encontram no universo de fins a que esse consentimento, de facto, se destina.

De resto, incumbe ao responsável pelo tratamento a demonstração das condições de validade da prestação do consentimento, nomeadamente que, no tratamento em causa, é possível retirar ou recusar o consentimento sem que o titular fique prejudicado, por exemplo, sem que exista uma consequência negativa ou de qualidade quanto à prestação de serviço em que aquele eventualmente assente.

É com base nestas premissas que, na prestação de consentimento, se haverá de ajuizar as circunstâncias fácticas/concretas em que aquele possa ser prestado, e se reserva especial atenção aos contextos de desequilíbrio de poder, situações em que (na medida em que se conceba que a situação não é de monta a ferir geneticamente o uso desse fundamento), o ónus de garantia da liberdade declarativa do titular deve ser reforçado e, inequivocamente, alheado qualquer prejuízo ou influência direta na vontade de consentir, v.g., sofrer o titular qualquer pressão ou influência nesse sentido.

O consentimento não pode, pois, ser condicionado. Quer isto dizer, *e.g.*, que o consentimento associado à aceitação de condições gerais ou a uma execução de contrato ou prestação de serviço que não seja necessário para essa execução ou prestação deve, também, ser afastado.

Simplificando, o tratamento de dados pessoais relativamente ao qual se pede o consentimento não poderá servir contrapartida direta ou indireta da execução de um contrato ou prestação de um serviço nem, tampouco, por se não confundirem os fundamentos do tratamento, ser o consentimento elemento subordinante à prestação do serviço ou execução contratual, sob pena de se eliminar, novamente, o conceito de liberdade por que se partiu.

Um outro importante elemento a conformar a noção de liberdade de consentimento é a que vulgarmente se designa de granularidade. Numa estocada prática, no caso de um serviço envolver várias operações de tratamento para mais do que uma finalidade, os titulares dos dados devem poder escolher quais as finalidades que aceitam e não serem colocados na circunstância de consentir “em bloco”, a obviar à especificidade e correspondente liberdade exposta supra.

Este último requisito deverá ser lido em conjunto com a especificidade do consentimento, desta feita construído no sentido de se assegurar efetivo controlo e transparência dos dados em relação ao seu titular, *i.e.*, na especificação do consentimento em função das (ou de cada uma das) finalidades do tratamento, e na separação clara entre as informações relacionadas com a obtenção do consentimento para as concretas atividades de tratamento de dados e as informações que lhes possam ser conexas, a executar atendendo à referida granularidade.

O consentimento específico haverá, assim, de só poder ser obtido quando os titulares dos dados são *especificamente* informados das finalidades previstas de utilização dos dados que lhes digam respeito.

Concretizando o que se vem dizendo, a informação do consentimento haverá de conter, no mínimo, a identidade do responsável pelo tratamento, a finalidade de cada uma das operações de tratamento em relação às quais se procura obter o consentimento, e que tipo de dados serão recolhidos e utilizados, e quais.

Correspetivamente, haverão de ser garantidos um conjunto de direitos-reflexo, como seja a existência do direito de retirar o consentimento, e o modo de o fazer, a prestação de informações acerca da utilização de dados para decisões automatizadas, em conformidade com o artigo 22.º, n.º2, alínea c), quando se verifique, e ainda sobre os possíveis riscos de transferências de dados, tal como previsto no artigo 46.º, todos do RGPD.

Igualmente, se o consentimento pretendido puder ser invocado por múltiplos responsáveis pelo tratamento, ou se os dados puderem ser transferidos ou tratados por outros responsáveis pelo tratamento que pretendam invocar o consentimento original, estes devem ser identificados.

Quanto ao *modus* de fornecimento de informação a materializar as condições do consentimento, exige-se que os responsáveis pelo tratamento utilizem uma linguagem clara e informal, de fácil compreensão para o cidadão comum, particularmente para os concretos destinatários titulares dos dados, de acesso fácil, e que permita distinguir os fins e a forma como os seus dados serão tratados, separando-os claramente de outros eventuais assuntos. Acresce, ainda, a informação acerca da pluralidade dos direitos que lhes assistem, a forma e *local* do seu exercício, bem como, naturalmente, qual ou quais os responsáveis pelo tratamento dos seus dados e os seus pontos de contacto.

Por tudo isto, exigir-se-á também que o titular dos dados deverá, sempre, agir deliberadamente para consentir o tratamento dos seus dados, enquanto irradiação de um “ato positivo inequívoco”, como plasmado no artigo 4.º n.º 11 do RGPD.

Destarte, não se haverá de considerar o consentimento por válido se se reduzir à utilização de opções pré-assinaladas de adesão, ou atribuir-se ao silêncio ou inação do titular um conteúdo declaratório positivo, a que acrescerá, como resulta do previamente exposto, repita-se, a impossibilidade do condicionamento do consentimento à aceitação generalizada de termos ou de conteúdo contratual.

Antes, deve o ato resultar de uma manifestação explícita, e que permita a demonstração da sua validade especificada por parte do responsável pelo tratamento - ónus que, como se viu, materialmente sobre si incide-, devendo ainda o responsável poder demonstrar que o consentimento foi obtido junto do titular dos dados, obrigação que subsiste, a esse título, enquanto durar o respetivo tratamento³.

Na verdade, sem necessidade de grandes construções, o artigo 7.º do RGPD isso mesmo declara, aí se fixando um conjunto de condições adicionais para a obtenção válida do consentimento.

Como se disse, a fundamentação de um tratamento de dados pessoais nos pressupostos do consentimento enquanto ato volitivo e disponível, implica também, como contraponto, um aspecto fundamental: o direito a que este possa ser retirado.

Como reflexo valorativamente equivalente à prestação do consentimento, a sua retirada deverá obedecer aos mesmos critérios de clareza e imediação, bem como os demais que supra se decompuseram, e poder ser exercida a todo o tempo, sem prejuízo para o titular ou sem que isso implique uma impossibilidade na execução de serviço, que desde logo demonstraria que, geneticamente, o consentimento estaria ferido de invalidade. Ainda que se reputasse que o vício existisse apenas no tocante à retirada do consentimento, o desrespeito pelo RGPD neste ponto contém a virtualidade de afetar todo o tratamento que assente nesse fundamento.

Quando a retirada do consentimento se verifique, o responsável pelo tratamento deverá parar o tratamento em causa. Regra geral, os dados devem ser apagados pelo responsável pelo tratamento (apesar da licitude do tratamento anterior ao exercício desse direito) no caso de não existir um outro fundamento jurídico/finalidade que justifique a continuação da sua conservação⁴.

Em concordância com o dito acima, e sob os requisitos do consentimento informado e ao abrigo do princípio da transparência, deve fazer-se constar expressa e claramente o direito de retirar o consentimento como

³ Findo que esse esteja, poder-se-á, também, cair nas malhas do artigo 17.º, alíneas b) e e) do RGPD.

⁴ Veja-se, a propósito, as exceções previstas no artigo 17.º do RGPD, bem como o disposto no seu Considerando 65.

informação ao titular dos dados em momento prévio a este prestar o seu consentimento, já que se trata de elemento fundamental em vista ao exercício do direito do titular e ao domínio e controlo do tratamento assente na sua vontade.

Finalmente, o responsável pelo tratamento não poderá transitar do consentimento enquanto fundamento para outros previstos no artigo 6.º do RGPD nem, tampouco, “aproveitá-lo” para outros fins que não aqueles que justificam o uso deste alicerce para o tratamento.

Ora,

Da singela regulação que o Legislador procurou empreender neste artigo 3.º, dificilmente se poderá aquilatar se estes pressupostos são -ou não- suscetíveis de serem cumpridos, podendo, contudo, afirmar-se, que não se encontrarão devidamente acautelados.

Que dados serão partilhados? Quem fornece o direito de informação? Como se exerce e perante quem o direito de retirada de consentimento? Qual ou quais as alternativas fornecidas? Que base de dados será utilizada? Que fluxo estará pensado, a refletir estes pontos?

Certo é que, alicerçando estes tratamentos nesse fundamento de licitude, para que estes sejam lícitos, o Legislador terá necessariamente modelar o cumprimento desses requisitos, o que não se verificará, por omissão.

Do traço genérico legislativo, poderá inclusivamente aferir-se que poderão estar em causa dois tratamentos de dados pessoais diferentes, aa endereçar, eventualmente, a fundamentos diversos - um respeitante aos beneficiários e sua adesão ao programa, e um outro, sob alçada da entidade competente, entre esta e as entidades proprietárias. A não previsão de nenhuma destas matérias ou arquiteturas não permite perceber qual o papel que cada um dos intervenientes terá neste(s) tratamento(s), e sua qualificação jurídica, nas obrigações e garantias que sobre cada um deles impendem.

Estes pontos são deveras importantes, desde logo por se alvejarem dados pessoais de menores que serão tratados e transmitidos, o que não poderá deixar de estar presente, e que impõe deveres acrescidos de tutela e salvaguarda, até na linguagem informativa a utilizar.

Como se escreve nas Diretrizes 05/2020 relativas ao consentimento na aceção do Regulamento 2016/679, emitidas pelo EDPB, p.29 e ss, *“O artigo 8.º introduz obrigações adicionais para assegurar um nível reforçado de proteção dos dados das crianças em relação aos serviços da sociedade da informação. As razões para o reforço da proteção encontram-se especificadas no considerando 38: «[...] podem estar menos cientes dos riscos, consequências e garantias em questão e dos seus direitos relacionados com o tratamento dos dados pessoais. [...]» O considerando 38 também determina que: «Essa proteção específica deverá aplicar-se, nomeadamente, à*

utilização de dados pessoais de crianças para efeitos de comercialização ou de criação de perfis de personalidade ou de utilizador, bem como à recolha de dados pessoais em relação às crianças aquando da utilização de serviços disponibilizados diretamente às crianças.» A expressão «nomeadamente» indica que a proteção específica não se limita à comercialização ou definição de perfis, incluindo também a «recolha de dados pessoais em relação às crianças» mais abrangente.”

Não existindo qualquer indicação ou regimentação sobre estas matérias, não é possível ajuizar acerca do fundamento de licitude de que se pretende lançar mão, não podendo deixar-se, todavia, de deixar as considerações precedentes, uma vez que estas refletem sobre toda a ontologia que se pretenderá – ou não – permitir construir.

Sublinhe-se que os dados apenas poderão ser tratados, nos termos do previsto no artigo 6.º do RGPD, se: a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas; b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados; c) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; d) O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular; e) O tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento; f) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança,

Se, na verdade, alguns desses fundamentos se encontrarão evidentemente, em abstrato, afastados no caso concreto, outros, como, por exemplo, os previstos nas alíneas c) e e), poderão presumir-se cogitáveis, mas que obrigariam a uma realização legislativa conforme os seus requisitos, face a cada um dos tratamentos propostos.

Acresce, ainda, que no artigo 4.º da Portaria se prescreve “4- Após receber a informação sobre o beneficiário, a entidade proprietária torna-se a responsável exclusiva pelo tratamento de dados pessoais, em conformidade com o quadro legal aplicável”.

Face ao que se expôs, não é possível alcançar com clareza a hermenêutica do preceito, uma vez que se encontra afetada irremediavelmente pelas lacunas apontadas, para além de que a entidade proprietária será, seguramente, responsável pelo tratamento pela informação que lhe será transmitida, exclusivamente para os fins que sobre si impendem, como seja, permitir acesso a uma sua publicação periódica, nada se prescrevendo, todavia, sobre os

demais determinações e obrigações que possam impender sobre os outros intervenientes nos tratamentos, e a que título.

Bastará fazer-se a pergunta sobre quem determina os fins e os meios de tratamento, ou como, quais e perante quem podem os titulares dos dados exercer os direitos que lhes sejam aplicáveis e garantidos nos artigos 14.º a 22.º do RGPD para se notar que o fundamento de licitude, a qualificação do regime de responsabilidade e o exercício dos direitos dos titulares se encontram intrinsecamente co-dependentes e que, em qualquer caso, não encontram qualquer previsão legislativa.

Note-se que um responsável pelo tratamento determina as finalidades e os meios do tratamento, ou seja, o **porquê** e o **como** do tratamento, e é definido pelo artigo 4.º, ponto 7, do RGPD como “a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro. [sublinhado nosso]

Como se faz constar nas Orientações 07/2020 sobre os conceitos de responsável pelo tratamento e subcontratante no RGPD⁵, “Embora o artigo 4.º, ponto 7, apenas faça referência «ao responsável pelo tratamento» no singular, o CEPD considera que pode também ser possível que o direito da União ou de um Estado-Membro designe mais do que um responsável pelo tratamento, possivelmente até mesmo como responsáveis conjuntos pelo tratamento. Sempre que o responsável pelo tratamento tenha sido especificamente identificado por lei, tal será determinante para estabelecer quem está a agir como responsável pelo tratamento. Tal pressupõe que o legislador tenha designado como responsável pelo tratamento a entidade que tem uma capacidade genuína para exercer o controlo.. Contudo, mais comumente, ao invés de nomear diretamente o responsável pelo tratamento ou de definir os critérios para a sua nomeação, a lei estabelecerá uma tarefa ou imporá a alguém a obrigação de recolher e tratar determinados dados. Nesses casos, a finalidade do tratamento é amiúde determinada pela lei. Normalmente, o responsável pelo tratamento será o designado por lei para a realização desta finalidade, esta tarefa pública.

A qualificação de quem é o responsável pelo tratamento, ou o seu regime – conjunto ou não – haverá sempre de partir da conceção prévia e particular do tratamento em causa.

⁵ Disponível em https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-10/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_pt.pdf

O mesmo se diga, também, quanto ao período de conservação dos dados, a sua eliminação, e a ontologia de dados e registos a ser concebida e sua forma de partilha, nomeadamente as medidas técnicas e organizativas a deverem ser aplicadas aos tratamentos⁶, que também constituem aspetos materiais inafastáveis na proteção de dados.

A ausência destes elementos conformadores impossibilita qualquer avaliação propedêutica de garantia dos direitos dos cidadãos, constituindo omissões a reparar, desde logo na concretização do princípio da menor intrusão na esfera dos titulares dos dados.

Prejudicada também se encontra qualquer pronúncia quanto ao conteúdo do artigo 6.º da Portaria, uma vez que se alude ao regime respeitante a recebimento pela entidade competente de relatórios agregados remetidos pela AMA, IP, desconhecendo-se em absoluto, como se disse, qual a intervenção particular nos termos do tratamento, ou a relação, dinâmica ou condições a estabelecer entre as entidades a que se estará a reportar, apesar de se louvar a referência à anonimização dos dados.

Finalmente, diga-se, ainda, que a Proposta e Portaria *sub iudice* não se encontram suportadas num estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais o qual é, recorda-se, obrigatório nos termos nos termos conjugados dos artigos 18.º, n.º 4, da Lei 43/2004, 7.º da Lei 58/2019, e 35.º do RGPD.

Tal omissão também compromete uma avaliação quanto aos prováveis riscos decorrentes dos tratamentos de dados pessoais a realizar e, sobretudo, poderá prejudicar a decisão ponderada dos titulares do poder político-legislativo numa matéria em que a compreensão de tais riscos é essencial para concluir, no plano normativo, quanto à admissibilidade e condições de execução dos novos tratamentos de dados, de forma ainda mais premente quanto estão em causa dados de menores, qualificados como pessoas vulneráveis e de risco incrementado nos termos do RGPD⁷, e portanto, avaliação que será também suscetível de ser enquadrada, por outra via e face a esta natureza, na eventual necessidade de avaliação de impacto prevista no artigo 35.º do RGPD.

CONCLUSÃO

Nos termos e com os fundamentos expostos a CNPD recomenda:

- a. Pautar o regime de tratamento de dados pessoais em instrumento de natureza legislativa, e não em Portaria;

⁶ Sobre esta matéria, pode ver-se a Diretriz 2023/1 desta Comissão.

⁷ Veja-se, por exemplo, o plasmado no Considerando 75.

- b. Estabelecer, em concreto, quais os tratamentos de dados em causa e, bem assim, o fundamento de licitude em que assentam e suas justificações, desenhando regime com eles concordante;
- c. Especificar quais os dados pessoais que serão tratados e suas categorias, a aferir face ao princípio da minimização, bem como o seu fluxo, em cada um dos tratamentos que se propõe;
- d. Especificar quais os responsáveis pelo tratamento, considerando o ponto anterior;
- e. Estabelecer quais os direitos que assistem aos titulares dos dados, bem como perante quem e como podem ser exercidos;
- f. Estabelecer o período de conservação dos dados e as condições do seu apagamento;
- g. A realização de avaliação de impacto dados pessoais, seja por via da obrigatoriedade prevista nos termos conjugados dos artigos 18.º, n.º 4 da Lei 43/2004, 7.º da Lei 58/2019 e, atenta a natureza dos dados em causa, nos termos do artigo 35.º do RGPD.

Aprovado na reunião de 21 de janeiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**
Data: 2025.01.21 19:44:27+00'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

